



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani	Presidente
dott. ssa Daniela Marconi	Giudice a latere
dott. ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6082/2018** promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ANTIVALLE ELENA

ATTORE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. GIAMBELLINI ORESTE DOMENICO

CONVENUTO

OGGETTO: azione di ripetizione d'indebito relativa al ri-trasferimento di partecipazione sociali oggetto di un patto fiduciario a seguito dell'estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica, qui di seguito riportati

Per parte attrice

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Imprese – B - r.g. 6082/2018 – Dott.ssa Maria Antonietta Ricci

*

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER L'ATTRICE *Parte_1*

*

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza e premessa ogni occorrente declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

- **Accertare e dichiarare** la mancata riassunzione del procedimento a seguito della sentenza n. 8358/2007 della Corte di Cassazione ex art. 392 c.p.c. e l'estinzione dell'intero processo, ex art. 393 c.p.c., e conseguentemente:

- **accertare e dichiarare** il diritto della sig.ra *Parte_1* di ottenere la ripetizione di quanto corrisposto al sig. *Controparte_1* per effetto delle statuizioni emesse nel procedimento conclusosi con sentenza n. 8358/2007 della Corte di Cassazione;

- **condannare** il sig. *Controparte_1* a reintestare alla sig.ra *Parte_1* la quota corrispondente al 9,592% del capitale sociale della società *Controparte_2* la quota corrispondente al 3,6% del capitale sociale della società *Org_1* e la quota corrispondente al 3% del capitale sociale della società *Parte_2* con effetto a far tempo dal novembre 2001, ponendo oneri, spese, imposte necessarie per la reintestazione a carico di *Controparte_1* nonché

- **condannare** il sig. *Controparte_1* a corrispondere alla sig.ra *Parte_1* i frutti e/o proventi e/o ogni altra utilità dallo stesso percepita a far tempo dal novembre 2001 e fino alla data di reintestazione, in forza della detenzione delle quote di proprietà della sig.ra *Parte_1* nelle società [...] *CP_2* *Org_1* e *Parte_2* con riserva di meglio quantificarli in corso di causa e, comunque, per un importo non inferiore ad Euro 126.446,36 oltre ad interessi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- **Acquisire** la documentazione prodotta;

- **accogliere** le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulate, nei confronti di *Controparte_1* nonché, se necessario, nei confronti di *Controparte_2* *Parte_2* *Org_1* nel paragrafo III della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. dell'odierna attrice, aventi per oggetto:

☐ l'esibizione dei libri sociali (ossia libro soci, libro verbali assemblee e, ove esistente, libro adunanze del Consiglio di Amministrazione) delle società *Controparte_2* *Parte_2* ed *Org_1* dal 2001 ad oggi;

☐ l'esibizione della contabilità della *Controparte_2* *Organizzazione_2* indicante i movimenti di denaro da parte delle predette tre società a favore di *Controparte_1* dal 2001 ad oggi;

- **ammettere** l'interrogatorio formale del sig. *Controparte_1* e la prova per testi sui capitoli di prova dedotti dall'attrice, *sub* nn. 1 – 10, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;

- **disporre** apposita CTU tecnico/contabile onde poter determinare l'ammontare dei frutti, proventi e/o utilità percepiti dal sig. *Controparte_1* in forza della detenzione delle quote di proprietà della sig.ra *Parte_1*

- **accogliere** tutte le domande, istanze ed eccezioni comunque formulate, in via istruttoria nonché a prova contraria, dall'attrice;

- **rigettare** le domande, istanze ed eccezioni formulate, anche a prova contraria, dal convenuto, ivi compresa la richiesta di interrogatorio formale della sig.ra *Parte_1* rigettando altresì l'ammissione dei capitoli di prova formulati dal convenuto, *sub* nn. 1 – 10, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;

- nel denegato caso di ammissione della prova per testi formulata dal convenuto, **disporre** l'ammissione dell'attrice a prova contraria, anche per testi, con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove *ex adverso* formulate.

Milano, lì 18 settembre 2020

Per parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale,

nel merito:

- previo, se del caso, riconoscimento della legittima proprietà da parte del Sig. *Controparte_1* delle partecipazioni societarie per cui è causa, comunque rigettare tutte le domande attoree in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese ed onorari.

In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione delle risultanze istruttorie di cui al procedimento estinto mediante acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alla causa tenutasi, tra le medesime parti, avanti al Tribunale Civile di Como R.G. n. 2133/95, nonché avanti alla Corte d'Appello di Milano R.G. n. 2943/01 e come meglio citato nella parte "IN

FATTO" dei precedenti atti, affinché codesto Tribunale ne possa tener conto ai fini del decidere;

- nell'ipotesi in cui l'Autorità Giudicante, per qualsiasi motivo, dovesse ritenere opportuno risentire gli stessi testi sui medesimi capitoli di prova riportati nelle copie autentiche dei verbali di causa prodotti con i docc. 4 e 5, si chiede ammettersi prova per interpellato dell'attrice e testi sui seguenti capitoli di prova::

1. vero che tutte le vicende e le pratiche relative alla costituzione, all'intestazione delle quote e ai successivi passaggi di titolarità di alcune di esse quote relative alle società *Parte_2* *Org_1* *Controparte_2* *Organizzazione_3* sono state curate, seguite e svolte

Persona_1, il quale è stato incaricato dal signor *CP_1* i fare intestare o di intestare alcune quote e di tali società alla moglie signora *Parte_1* fermo restando che il capitale necessario per la sottoscrizione delle quote o per l'acquisto di alcune di esse da terzi, soci di minoranza di tali società, veniva messo a disposizione dallo stesso signor *CP_1*

2. vero che la signora *Parte_1* nel partecipare alle operazioni che sono state compiute per rendere alla stessa possibile di div *ia* di minoranza delle società sopra indicate, ha riconosciuto e dichiarato che i capitali utilizzati per tali operazioni erano del marito ed ha riconosciuto che da parte Sua si assumeva la veste di apparente socio in via fiduciaria, in quanto le quote dovevano intendersi, ed erano effettivamente, di esclusiva appartenenza del signor *Controparte_1*

3. vero che, sia in occasione della intestazione delle quote di minoranza a favore della signora *Parte_1* e relativa alle società indicate, sia anche successivamente, in diverse occasioni, la signora *Parte_1* a sempre dichiarato e riconosciuto di essere socia apparente di esse società, in quanto l'intestazione ad essa delle quote di sua apparente attribuzione era avvenuta per volontà del marito ed ha sempre ammesso che, in qualsiasi momento a richiesta del marito, si sarebbe prestata a retrocedere o ritrasferire, senza diritto a percepire alcun corrispettivo, a favore od in testa al marito o di altra od altre persone che il marito avesse inteso indicare le quote di cui sopra;

4. vero che, in occasione di alcune operazioni dirette ad intestare alcune quote di partecipazione alle società indicate, si è fatto figurare, per ragioni di carattere fiscale e valutario, che i capitali per l'intestazione o l'acquisto delle quote di poi intestate alla signora *Parte_1* erano stati messi a disposizione della signora *Parte_1* dalla di lei madre, che era cittadina svizzera e vero che i capitali apparentemente di disponi *madre della signora Parte_1* in precedenza erano stati ceduti o versati alla madre *Parte_1* dal padre del signor *CP_1* n *he la madre* della signora *Parte_1* li mettesse a disposizione della figlia per far risultare ed apparire che la figlia aveva sottosc *uistato con mezzi propri la titolarità delle quote alla stessa attribuite;*

5. vero che il 19/12/1988 l' *Organizzazione_4* per incarico del signor *CP_1* ha ceduto alla signora *Parte_1* una quota *Org_1* il prezzo della cessione pagato dal signor *CP_1* in quanto tra le parti si era convenuto che l'intestazione della quota doveva apparentemente a favore della signora *Parte_1* fermo restando che essa quota di fatto era di appartenenza del signor *CP_1*

6. vero che il 16/10/1986 il signor *Controparte_1* tramite l' *Organizzazione_4* ha intestato una quota della *Org_1* alla ex moglie *Parte_1* senza che la stessa versasse il corrispettivo relativo al valore della quota e con l'acordo di intestazione apparente, nel senso che di fatto la quota era del marito e la moglie avrebbe dovuto retrocederla o ritrasferirla a semplice richiesta del signor *CP_1*

7. vero che la *Controparte_2* è stata costituita il 13/10/1981 e che, fin dalla costituzione, una quota di Lire 9.800.000= per volontà del signor *CP_1* alla signora *Parte_1* la quale non ha versato l'importo ad essa relativa che è stato, invece, corrisposto dal signor *CP_1* e vero che quando l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento di capitale di tale società, l' *Org_1* l'aumento per un ammontare di Lire 230.000.000= attribuita alla signora *Parte_1* è stata interamente pagata dal signor *CP_1* vero che, anche in tale occasione e successiva *Controparte_1* ha sempre dichiarato che nella realtà le quote erano di esclusiva appartenenza del signor *CP_1* che essa restava obbligata, in qualsiasi momento e a semplice richiesta del marito, a ritrasferire le quote senza diritto a corrispettivo a favore del marito o di persona da lui indicata;

8. vero che in data 20/02/1986 il signor *Persona_2* padre del signor *Controparte_1* ha ceduto una quota di partecipazione della *Org_1* signora *Parte_1* con l'indicazione del figlio *Controparte_1* avendo le parti stabilito che l'intestazione avveniva apparentemente a favore della signora *Parte_1* mentre nella realtà le quote erano di appartenenza del signor *Controparte_1* che, anche di fatto, ha provveduto a pagare il prezzo di cessione;

9. vero che in data 31/03/1987 la società sopra indicata è stata trasformata in S.r.l. con aumento di capitale e vero che le quote di aumento di capitale attribuite alla signora *Parte_1* ed intestate alla stessa, sono state pagate dal signor *CP_1* che ha messo a disposizione il capitale;

10. vero che in data 02/07/1992 il signor *Controparte_1* ha ceduto una quota di nominali Lire 60.000.000= alla moglie e vero che, sia in occasione di aumento di capitale sia in occasione della cessione della quota, la signora *Parte_1* ha sempre riconosciuto e dichiarato che si trattava di cessione, attribuzione, intestazione apparente le quote dovevano intendersi di appartenenza esclusiva del marito ed ha sempre ribadito il proprio impegno a ritrasferire a richiesta del marito le quote in testa al marito o a persona da lui indicata.

Si indicano quali testimoni i Sigg.ri:

- *Persona_1* (cod. fisc.: *CodiceFiscale_1*), residente in Via Rovelli n. 51, 22100 – Como;
- *CP_3* (cod. fisc.: *CodiceFiscale_2*), residente in Via Vittorio Veneto n. 3, 22073 – Fino Mornasco (CO);
- *Controparte_4* (cod. fisc.: *CodiceFiscale_3*), residente in Via Conciliazione n. 29, 22100 – Como;
- *Controparte_5* residente in Via Zezio n. 28, 22100 – Como. - ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova così come formulati dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.;

- si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi dal Giudice con i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2) c.p.c.;

- ci si oppone all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nonché alla richiesta di CTU tecnico/contabile formulata dall'attrice per i motivi esposti al punto 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Le pregresse vicende processuali

La presente controversia segue ad un precedente giudizio tra le due parti in lite- gli ex coniugi [...] *Parte_1* ed *Controparte_1* estintosi per mancata riassunzione del processo innanzi alla Corte D'Appello territoriale, a seguito di cassazione con rinvio della pronuncia resa in seconde cure.

Il tema del contendere si riferisce alla titolarità delle seguenti quote:

- il 9,592% del capitale sociale di *Parte_4*
- il 3% del capitale sociale di *Parte_2*
- il 13,6% del capitale sociale di *Org_1*

Per una migliore comprensione delle vicende processuali, di seguito vengono riassunti i passaggi salienti della prima lite.

- I. Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 1995, *Controparte_1* ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Como *Parte_1* al fine di fare accertare l'intestazione fiduciaria -a favore della convenuta nella veste di fiduciaria- delle quote di partecipazione delle tre società sopra indicate, con conseguente accertamento dell'obbligo restitutorio e condanna alla re-intestazione dello stesso attore, nella veste di fiduciante. Costituendosi, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese di controparte. Con pronuncia n. 1046/2001, il Tribunale ha accolto con la domanda attorea accertando il patto fiduciario e condannando *Parte_1* alle conseguenti restituzioni..
- II. A seguito della sentenza di primo grado, *Parte_5* ha proceduto in via autonoma alla re-intestazione a proprio favore delle quote litigiose nel mese di novembre del 2001, con iscrizione nel registro delle imprese (di protocollo 23-26.11.2001).
- III. Gravata la sentenza in prime cure, la Corte d'Appello territoriale con pronuncia n. 2474/2002 ha respinto il gravame proposto da *Parte_1* anche in virtù di due documenti introdotti per la prima volta in secondo grado dall'appellato, a conferma della provenienza da parte dello stesso *Controparte_1* delle provviste per l'acquisto delle quote litigiose.
- IV. La sentenza di secondo grado -integralmente impugnata da *Parte_1* con pronuncia n. 8358/2017 è stata cassata con rinvio dalla Corte di legittimità; alla luce del nuovo indirizzo interpretativo dell'art. 345 c.p.c., sono stati ritenuti non legittimamente introdotti da parte dell'appellato i nuovi documenti- ancorché prove precostituite- in secondo grado. La Cassazione ha quindi disposto che la Corte d'appello riformulasse il proprio apprezzamento di merito sulla scorta solamente degli altri elementi di prova raccolti. In proposito, ha ritenuto corrette le valutazioni positive espresse del giudice di seconde cure sull'ammissibilità delle prove testimoniali assunte in primo grado, sia quanto alla capacità sia quanto all'attendibilità.
- V. Il giudizio di rinvio, come accennato, non è stato riassunto nei termini di legge.

2. La presente lite

In data *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Parte_5* chiedendo: 1. l'accertamento della mancata riassunzione del primo processo a seguito della cassazione con rinvio della Suprema Corte, con conseguente estinzione ex art. 393 c.p.c. e caducazione delle sentenze di primo e secondo grado; 2. la condanna del convenuto alla re-intestazione delle quote sociali oggetto di lite; 3. la condanna del convenuto a restituire i proventi e i frutti maturati a decorrere dal mese di novembre 2001, quantificati in un importo non inferiore ad € 126.446,36.

Il convenuto, costituendosi, ha così concluso:

“previo, se del caso, riconoscimento della legittima proprietà da parte del Sig. Controparte_1 delle partecipazioni societarie per cui è causa, comunque rigettare tutte le domande att date in fatto ed in diritto.”

Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. parte attrice ha precisato la propria domanda, riconducendola all'alveo del rimedio di cui all'art. 2037 c.c., essendo venuta meno – a seguito dell'estinzione del primo processo- la *causa acquirendi* del convenuto.

Nella terza memoria, la difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione della domanda di ripetizione promossa da controparte.

Ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza necessità, di dare ingresso all'istruzione probatoria, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione innanzi al Collegio, previa concessione dei termini abbreviati per il deposito degli scritti difensivi finali.

3.L'estinzione del primo processo ed i suoi effetti

Seppure la competenza a pronunciare sull'estinzione ex art. 393 c.p.c. spetti in via generale al giudice del rinvio -il quale provvede ai sensi dell'art. 308 c.p.c.- è ammesso per indirizzo consolidato che tale declaratoria possa essere compiuta, in via incidentale o pregiudiziale, dal giudice al quale la domanda restitutoria conseguente all'effetto estintivo è formulata.

Infatti, la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione fa venir meno la speciale competenza del giudice del rinvio per quanto riguarda gli obblighi restitutori. Con la conseguenza che la domanda va proposta all'Ufficio competente secondo le regole comuni, il quale può pronunciare *incidenter tantum* l'estinzione del giudizio del rinvio. L'indirizzo è pacifico preso la Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 10352/93).

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, è competente sia per territorio sia per materia rispetto alle questioni sottoposte al suo sindacato: tale profilo è pacifico e non oggetto di discussione tra le parti.

E' altresì incontestato che nessuna delle parti abbia riassunto il processo innanzi alla Corte territoriale nel termine ex art. 392 c.p.c. a seguito della citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 8358/2017.

Considerato che l'oggetto principale del presente giudizio corrisponde a quello del primo processo, giacché in entrambi i casi il bene della vita sotteso è la titolarità delle partecipazioni sopra citate per l'esistenza o meno di un patto, va dunque dichiarata incidentalmente l'estinzione della prima lite.

4. L'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito

4.1. Il convenuto ha svolto solo nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. l'eccezione di prescrizione decennale della domanda attorea.

4.2. Tale censura è tuttavia tardiva, come tempestivamente eccepito da parte attrice nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.. La prescrizione, come noto, è un'eccezione in senso stretto e deve essere sollevata nella prima difesa utile: Controparte_1 non ha tuttavia speso tale fatto estintivo nella comparsa di costituzione e risposta (e neppure nella prima udienza di trattazione e, ancora, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1. c.p.c.), decadendo definitivamente quindi da tale facoltà processuale.

4.3. A tale conclusione non osta la difesa del convenuto, che ha sostenuto la tempestività della propria doglianza: solo con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. controparte avrebbe modificato il *thema decidendum*, riconducendo esplicitamente la propria pretesa all'alveo dell'art. 2037 c.c. ed aggiungendo la domanda di accertamento del diritto alla ripetizione delle quote litigiose, così consentendo alla difesa di Controparte_1 solo nell'ultima memoria di comprendere la portata delle pretese avversarie e di eccepire la prescrizione.

Tale difesa è infondata, giacché la domanda attorea era delineata nei suoi elementi costitutivi sin dall'atto di citazione. Ed in particolare erano sufficientemente specificati:

- la *causa petendi* ossia la caducazione delle sentenze di primo e secondo grado;
- il *petitum c.d. immediato*, ovvero la condanna alla restituzione delle quote;
- il *petitum c.d. mediato*, qui il diritto a rientrare nella titolarità delle quote litigiose.

L'eccezione di prescrizione svolta dal convenuto va dunque in conclusione respinta, perché tardivamente formulata.

5. Nel merito: la domanda attorea di ripetizione dell'indebito

5.1. la mancanza di uno degli elementi costitutivi dell'azione: la traditio

La domanda di parte attrice è infondata per un primo ordine di motivi.

Come noto, la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 e segg. c.c. richiede i presenti requisiti:

a) la *traditio* da parte del *solvens*;

b) l'assenza- originaria o sopravvenuta- di una valida causa giustificativa dell'attribuzione.

Nel caso in esame, al contrario, manca il primo requisito, ossia la *datio* dall'attore al convenuto in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, *medio tempore* caducate.

Invero, secondo la stessa prospettazione di parte attrice (cfr. punto n. 5 dell'atto di citazione) il convenuto – a seguito della pronuncia di primo grado del Tribunale di Como a sé favorevole ma non esecutiva (in quanto di natura costitutiva e non passata in giudicato)- ha provveduto in via autonoma e “senza coinvolgerla” a re-intestarsi le quote litigiose con la semplice annotazione a libro soci.¹ E ciò approfittando, secondo la stessa allegazione attorea, del duplice ruolo dallo stesso CP_1 rivestito – di socio di maggioranza e di amministratore- delle tre società le cui partecipazioni sono oggetto di lite.

Manca dunque il presupposto dell'indebito oggettivo perché -venute meno le pronunce di primo e secondo grado- il trasferimento trova giustificazione autonoma in una condotta che, secondo la prospettazione della stessa attrice, aveva connotati pressoché usurpativi, dunque illeciti e non meramente indebiti, *ab origine*.

5.2. L'eccezione del convenuto di essere legittimo titolare delle quote litigiose

5.2.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'attrice

In ogni caso, anche ove si ritengano sussistenti tutti i requisiti costitutivi della tutela ex art. 2033 c.c. - aderendo cioè all'indirizzo secondo il quale il rimedio restitutorio ricomprenderebbe ogni tipo di *retentio* ingiustificata e di trasferimento senza causa originaria (quale mezzo di tutela generale nel cui alveo sarebbero da ricondurre tutte le *conditiones* di derivazione romanistica), la domanda attorea va comunque respinta.

Il convenuto ha infatti eccepito la legittima titolarità delle quote litigiose, invocando il patto fiduciario che vincolava le parti, nel quale lo stesso Controparte_1 ricopriva la veste di fiduciante e Pt_6 [...] quella di fiduciario. Seppure implicitamente, il convenuto sottende nella propria difesa il conseguente obbligo di ri-trasferimento a carico dell'attrice.

La chiarezza e la portata di tale prospettazione difensiva è stata del resto subito colta dalla stessa difesa di parte attrice, che ha sollevato a sua volta- in questo caso tempestivamente- l'eccezione di prescrizione delle pretese del convenuto. Tale fatto estintivo decorrerebbe a suo dire dal 21.10.1995, data di notifica dell'atto di citazione con la quale controparte ha avviato il primo giudizio azionando, per la prima volta ed in via principale, il *pactum fiduciae* (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice).

La censura di prescrizione- questa volta sollevata tempestivamente dall'attrice- è infondata nel merito.

In proposito va rammentato che:

a) dal lato del fiduciante, il *pactum fiduciae* - di tipo romanistico, con conseguente effettivo trasferimento del diritto in capo al fiduciario- ed il relativo obbligo restitutorio possono essere infatti azionati dal fiduciante dal momento in cui tale obbligazione è esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine se l'accordo lo prevede ovvero, in mancanza, dalla data in cui il fiduciario manifesta la propria

¹ Nel registro delle Imprese risultano trascritti i corrispondenti “trasferimenti di quote” con la menzione “Tribunale di Como” (cfr. docc. 1, 2 e 3 di parte attrice).

volontà di non adempiere all'obbligazione restitutoria. Da tale termine inizia a decorrere la prescrizione contrattuale, di durata decennale;

b) nel caso in esame, nessuna delle parti ha allegato la pattuizione di un termine *a quo*. Con la conseguenza che l'obbligo di ritrasferimento a favore del convenuto-fiduciante è esigibile e la relativa prescrizione decorre dalla data in cui quest'ultimo ha avuto conoscenza formale che controparte non intendeva riconoscere la legittimità della situazione formale *medio tempore* posta in essere dall'ex marito -e ribadita da quest'ultimo anche alla luce del proprio originario obbligo restitutorio sotteso al *pactum fiduciae*,- e richiedendo la condanna alla restituzione delle quote di partecipazione;

c) qui come rammentato, successivamente all'avvio del primo processo e nelle more tra il primo e secondo grado di giudizio, e precisamente nel 2001 il fiduciante è divenuto infatti formalmente intestatario delle quote litigiose, e precisamente nel 2001, esercitando da tale momento le relative prerogative, mentre il fiduciario non è più nella disponibilità da quasi venti anni. L'interposizione reale è dunque venuta meno, consolidandosi la titolarità in capo al soggetto creditore dell'obbligo restitutorio;

d) solo con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, *Controparte_1* è stato reso edotto della volontà del fiduciario di contestare tale nuova situazione formale e sostanziale- a parti invertite rispetto al primo giudizio- e domandando la re-intestazione delle quote. Sul punto infatti, il convenuto ha disconosciuto come non proveniente dalla propria sfera soggettiva il carteggio agli atti del 2015- come le comunicazioni precedenti- tra i legali di parte attrice e le sole società delle cui partecipazioni qui si discute, ma non lo stesso *CP_1* cfr. docc. 7, 8 e 9 di parte attrice);

e) è dal 15.2.2018, data dalla notifica della presente lite, dunque, che occorre calcolare la decorrenza del termine di prescrizione decennale a carico del convenuto, il quale nella comparsa di costituzione e risposta ha tempestivamente eccepito di essere invece l'attuale legittimo titolare.

Tale eccezione non può dunque ritenersi prescritta.

Rileva per completezza l'Ufficio che -trattandosi la prescrizione di eccezione in senso stretto- vengono esaminate le sole vicende estintive afferenti a tale istituto dedotte dalla difesa attorea, qui come accennato ricondotta al solo atto di citazione del primo giudizio non essendo stata manifestata la volontà di approfittare di tale effetto a decorrere da altri eventi.

5.2.2 (segue) *Nel merito: la prova del patto fiduciario.*

Il perimetro delle prove versate agli atti e sulle quali il Collegio è chiamato a compiere il proprio apprezzamento si estende in particolare:

- a) alle prove orali raccolte nei precedenti gradi del processo estinto -costituenti in questa sede argomenti di prova liberamente valutabili dal giudice (cfr., tra le altre, Cass. n. 8603/2017, n. 840/2015)
- b) ai due documenti che erano stati ritenuti tardivamente depositati in sede dall'Appello dalla stessa Corte di Cassazione a seguito del mutamento del proprio indirizzo sull'ingresso delle prove precostituite per la prima volta in grado d'appello. In proposito, non opera qui il vincolo di cui all'art. 393 c.p.c. (*“la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la proposizione della domanda”*) giacché il principio di diritto su un *error in iudicando* enunciato dalla Corte di legittimità ha efficacia solo endo-processuale e non produce effetto vincolante in altri giudizi non di rinvio.²

² Cfr. Cass. 1989/1403, che sottende tale regola “questa Corte aveva annullato la sentenza di appello.. per motivi processuali. Pertanto, né si era formato un giudicato, opponibile nel processo attuale, né -d'altronde- era a parlare di un principio enunciato nella sentenza di rinvio che violasse il giudice di tale processo) cfr. più di recente Cass. 2008/28727 più esplicita (L'effetto vincolante non può essere che quello conseguente all'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c. che però nel caso di specie, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, non vi fu poiché questa Corte cassò soltanto per vizi di motivazione) cfr. sul

L'esame del materiale sopra descritto consente di ritenere fondata la doglianza del convenuto.

Risultano in particolare provati:

a. l'intestazione fiduciaria delle quote di partecipazioni litigiose a favore di *Parte_1* e non una mera intestazione fittizia.³ Tale scelta era stata compiuta dalle parti in conflitto, all'epoca coniugi, per rispettare il dettato normativo della pluralità dei soci di società di persone a responsabilità limitata, al tempo in vigore.⁴ Tutte le operazioni erano state compiute su incarico del convenuto.⁵

Si vedano in proposito le prove testimoniali rese da:

- *Persona_1*, commercialista del convenuto che ha curato direttamente tutte le operazioni sociali oggetto di lite, concordando le relative modalità;
- *Controparte_5* precedente titolare delle quote di *Or*, cedute a *Parte_1*
- *CP_3* e *Parte_6* figlie degli ex coniugi (cfr. doc. 4 di parte convenuta).

b. l'operazione di acquisto di tali quote era stata compiuta attraverso mezzi economici messi a disposizione dall'ex marito.⁶ Ed in particolare:

I. quanto ad *Org_1* l'acquisto delle quote di partecipazione dal precedente titolare⁷ all'odierna attrice è avvenuta con provvista del convenuto. Di tale circostanza sussiste:

- sia riscontro documentale;⁸

- sia prova testimoniale.⁹

Rispetto alle quote detenute in *Or* da *Organizzazione_5* le quote di partecipazione-intestate fiduciariamente al convenuto sono state intestate all'attrice senza passaggio di denaro;

II. quanto ad *Controparte_2* società di nuova costituzione, per l'acquisto delle quote di partecipazione dell'attrice sono state utilizzate somme direttamente prelevate dal conto corrente personale del convenuto e le relative operazioni sono state compiute solo su incarico esclusivo del convenuto;¹⁰

III. la cessione di quote di *Parte_3* dal padre del convenuto a favore dell'attrice¹¹ dissimulava una cessione al figlio.

punto tema anche Cass. 2012/14723 "la vincolatività, ai sensi dell'art. 393 c.p.c. del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione anche nel nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda non preclude alle parti la possibilità di proporre, nel nuovo procedimento, domande o eccezioni nuove a quelle proposte del processo estinto".

3 cfr. testimonianza resa ad esempio da *CP_3* in data 23.4.1999: *"l'intestazione delle quote doveva intendersi effettuata a suo favore, s'intende di mia madre, solo in via fiduciaria"*.

4 cfr. testimonianza resa da *Persona_1*, in data 10.7.1997, doc. 4 di parte convenuta.

⁵ cfr. testimonianza resa da *Persona_1* *"tutte le operazioni (..) sono state curate su incarico ricevuto personalmente ed esclusivamente da Controparte_1"*

6 cfr. dichiarazione resa da *Persona_1* *"il denaro occorrente per dette operazioni era di sua esclusiva pertinenza,"*, doc. 4 di parte convenuta.

7 cfr. testimonianza resa da *Controparte_5* in data 9.12.1999

8 cfr. doc. 1 di parte convenuta ove *Organizzazione_6* conferma di avere effettuato in data 8.5.1992 su ordine dell'allora marito *Controparte_1* per € 466.000,00 bonifico a favore della madre dell' *Parte_7* [...] stessa somma da questa poi donata alla figlia *Pt_1* (cfr. richiesta di registrazione al [...] *Org_7* del relativo atto di donazione, doc. 2 e 9 di parte convenuta;

9 cfr. dichiarazioni rese da *Controparte_5*, *CP_4* e *CP_3* nonché da *Persona_1*.

10 cfr. deposizione di *Persona_1* *"ricordo che per consentire l'aumento di capitale, credo della [...] CP_2 si procedette formalmente ad una donazione di denaro di titoli dalla madre della sig.ra Parte_1 cittadina svizzera, a quest'ultima" (..) "l'accordo di cessione era tra CP_5 e CP_1 L'assegno per il trasferimento della cessione è stato emesso e sottoscritto dal CP_1 .."*

11 cfr. doc. 8 di parte convenuta.

c. l'obbligo di *Parte_1* a richiesta del marito, di ritrasferire le quote litigiose a favore di quest'ultimo (ovvero ai figli, una volta divenuti maggiorenni) ossia al soggetto che aveva a suo tempo somministrato i relativi mezzi economici. Tale obbligo restitutorio di parte attrice a favore dell'ex marito è stato confermato dalle testimonianze rese sempre dalle figlie della coppia *Parte_8* *CP_3* e *CP_4* riferendo di conversazioni ripetute nel tempo in più occasioni. (cfr. verbali d'udienza del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Como, cfr .doc. 4 di parte convenuta).¹³

Il quadro indiziario sopra delineato -grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c.- conduce a ritenere dunque provato il *pactum fiduciae* e l'obbligo restitutorio in capo all'odierna attrice, senza necessità di procedere ad ulteriori attività istruttorie.

Tale eccezione paralizza dunque la domanda di *Parte_1* che va dunque respinta.

6. Il comando giudiziale

La domanda attorea va respinta per le ragioni indicate in narrativa.

Quanto al governo delle spese, ritiene l'Ufficio che la vicenda, intricata sotto il profilo processuale e fattuale, giustifichi l'integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, Sezione XV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *Parte_1* contro *Controparte_1* introdotta con atto di citazione notificato in data 15.2.2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:

1. accertata l'estinzione del processo introdotto in primo grado innanzi al Tribunale di Como in data 21.10.1995 da *Controparte_1* contro *Parte_1* per mancata riassunzione del processo a seguito della sentenza n. 8358/2007 resa dalla Corte di Cassazione, rigetta le domande dell'attrice per i motivi indicati in narrativa;
2. compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 15 aprile 2021

Il Presidente

dott. Angelo Mambriani

Il giudice istruttore

dott. ssa Alima Zana

12 cfr. testimonianza resa da *Persona_1*, “la cessione doveva considerarsi a favore del figlio”

¹³In particolare *CP_3* che ha confermato il capitolo n .3, avente ad oggetto l'obbligo di retrocedere o ritrasferire, senza diritto a percepire alcun corrispettivo, a favore od in testa al merito do altra o altre persone che il marito avesse inteso indicare (cfr. pagg n 76-.7 della comparsa di comparsa di costituzione e risposta che riporta i capitoli di prova della prima lite ed il documento n .4 del convenuto, con le relative testimonianze della figlia.